

1500165-40.2021.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500165-40.2021.8.26.0550 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-40.2021.8.26.0550 - 2021/000309

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE COLASANTO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE COLASANTO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 07 de maio de 2.021, por volta das 19:45 horas, na Rua 6, nº 52, Jardim Guanabara, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito 34 (trinta e quatro) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido de 4,92 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 56/67, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 07 de fevereiro de 2022.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional aberto, incidindo, ainda, a pena de perdimento sobre os valores apreendidos em poder do acusado, porque decorrentes da atividade ilícita.

Já a ilustre Defensora Pública, preliminarmente, sustentou assentada a materialidade do delito em prova ilícita, decorrente a apreensão do entorpecente de busca pessoal realizada ilegalmente pela Guarda Municipal, em circunstâncias não autorizadas, ademais, pelo artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, a determinar a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos II, do Código de Processo Penal. No mérito, entendendo insuficiente a prova produzida, pugnou também pela absolvição, aqui nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, reclamou a desclassificação, para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos, com o reconhecimento da atipicidade da conduta, seja em razão da inconstitucionalidade do disposto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, seja em função do princípio da insignificância, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em caso de acolhimento da pretensão acusatória, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, bem assim da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, operando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, em caso de reconversão, promovendo-se, por fim, a restituição dos valores apreendidos, facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Improcede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Sustenta-se que a materialidade do delito estaria assentada em prova ilícita, assim porque realizada busca pessoal ilegal pela Guarda Municipal, que atuou, ademais, em circunstâncias não autorizadas pelo que delineado no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, como também porque ausentes os fundamentos previstos no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ouvido em juízo, o acusado afirmou que na ocasião dos fatos estava caminhando pela via pública, após ter deixado um "carrinho de lanches", em local onde havia outras pessoas, quando foi abordado por Guardas Municipais, submetido em seguida a uma busca pessoal, com a apreensão de certa quantia em dinheiro decorrente de sua atividade laborativa. Acrescentou o acusado que os Guardas Municipais, com a utilização de um cão de faro, localizaram entorpecente nas imediações, que não lhe pertenciam, negando tivesse na ocasião admitido que estivesse realizando o comércio ilícito no local.

Os Guardas Municipais, que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, ouvidos em juízo, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de venda de entorpecente, onde avistaram o acusado, tendo ele, neste momento procurado se afastar, seguindo-se então uma abordagem. Esclareceram que não havia nenhuma denúncia de que naquele local estivesse ocorrendo o tráfico por parte do acusado, tampouco notaram qualquer movimentação dele sugestiva da realização do comércio ilícito. Acrescentaram que com ele não foi apreendido nenhum entorpecente, mas tão somente a quantia de cento e setenta reais. Com a utilização de cão de faro, ainda segundo o exposto pelos Guardas Municipais, nas proximidades, foram apreendidas trinta e quatro porções de cocaína, dizendo o acusado que lhes pertencia e que estava realizando o tráfico.

Não se ignora, até mesmo em função da recorrência desta controvérsia, que a segurança pública, voltada à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas, é exercida pelas Polícias Militares e Civis, estabelecida pela Constituição Federal a possibilidade de criação, pelos Municípios da Federação, de Guardas Municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E a Lei Complementar n. 13.022/14, destinada a regulamentar a atividade da Guarda Municipal, nos limites postos pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, não obstante objeções de inconstitucionalidade, procurou atribuir àquela corporação papel mais ajustado às adversidades da atualidade, conferindo-lhe a possibilidade de certa coadjuvância ou apoio na promoção da ordem e da segurança pública, consideradas em sentido mais amplo, sem invasão das competências das Polícias Civil e Militar.

No exercício desta atividade, de cooperação em proveito da segurança pública, em sentido amplo, tem os integrantes da Guarda Municipal se deparado com situações de estado flagrancial que possibilitam a atuação direta e autônoma, não fundada em suas competências, mas derivada do que disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal, que autoriza a qualquer do povo, nestas circunstâncias, efetuar a prisão em flagrante e adotar procedimentos correlatos invasivos a garantir a segurança do ato de contenção da ação delitiva.

Entretanto, neste caso, a situação é diversa.

De fato, os Guardas Municipais afirmaram que estavam em patrulhamento, a coibir o tráfico de entorpecentes no local, em ação que já traz questionamento sobre eventual desbordamento de sua competência funcional, quando avistaram o acusado, sem que houvesse qualquer movimentação sugestiva do comércio ilícito, tampouco qualquer denúncia que recaísse sobre ele, o que demonstra, por igual, sério questionamento sobre os fundamentos que autorizariam a abordagem, que somente pode decorrer de suspeita concreta e fundada, atendendo os pressupostos previstos no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sobre isto, superiormente têm-se afirmado que: “Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022 (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a atuação das guardas municipais e apresentou como conclusão, entre outras, que não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais e por isso interpretadas restritivamente nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária”.

E dada a similitude, calha a reprodução do que ainda ponderado naquele julgado: “No caso, guardas municipais estavam em patrulhamento com cão farejador de drogas na viatura quando avistaram o acusado e um adolescente, os quais, ao notarem a presença da guarnição, fugiram para dentro de um condomínio. Os agentes municipais, então, passaram a diligenciar para localizar os suspeitos e, depois de ouvirem barulho dentro de um dos apartamentos (apto. 14, bloco A), nele ingressaram e encontraram o réu o qual tinha drogas consigo escondido embaixo de uma cama. Em outro apartamento (apto. 2, bloco B), localizaram o adolescente que estava antes com o réu e, com a ajuda do cão farejador, mais drogas ali foram encontradas. 3. De plano, chama a atenção na narrativa o nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais, evidenciado de antemão pelo fato de que patrulhavam a região com um cão

farejador de drogas, a denotar a finalidade de coibir o tráfico, o que em nada se relaciona com a proteção do patrimônio municipal. 4. Os guardas municipais, a princípio, tinham apenas uma suspeita sobre o réu, baseada na fuga dele ao avistar a viatura, e não uma situação de flagrante visível. Ausente prévia e evidente situação de flagrância delitiva que eventualmente autorizasse a realização de prisão por qualquer do povo com fundamento no art. 301 do CPP, não cabia aos guardas municipais efetuar patrulhamento ostensivo com cão farejador de drogas e perseguir indivíduos suspeitos da prática de tráfico, sobretudo no caso dos autos, em que chegou a haver até mesmo ingresso em um apartamento para capturar o réu com base apenas na sua fuga, em absoluto desacordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores [...] 6. Assim, porque a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se impõe. 7. Ordem concedida para, considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram [...]" (HC742578/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJE 19/09/2022).

Do que vem de ser exposto, cotejando a prova produzida, tem-se que, no caso, não se demonstrou que a atuação da Guarda Municipal estava legitimada a partir das funções delineadas pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, realizando atividade típica de policiamento ostensivo, não socorrendo a possibilidade de atuação, ademais, de estado flagrancial que a justificasse, nos termos do disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal, crescendo-se que igualmente não se evidenciou a fundada suspeita que autorizaria a busca pessoal realizada, nos termos do disposto no artigo 240, § 1º, do mesmo Estatuto Processual Penal, que inclusive restou infrutífera, tudo a macular, por derivação, dada a ilicitude, a materialidade do delito, impondo-se, em consequência, o afastamento da pretensão acusatória.

Ante o exposto, e o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado LEONARDO HENRIQUE COLASANTO da imputação contra ele dirigida na denúncia. Oportunamente, promova-se a restituição dos valores apreendidos ao acusado.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA